刑法第十五講筆記

一試準備建議

- 一試不需要特別為選擇題額外準備，如果把二試的內容學好，一試的選擇題自然就能應付
- 重點在於對觀念的理解與體系的掌握

參與關係的終止未遂（§27 II）

一、與單獨犯終止未遂的差異

比較項目	單獨犯（§27 I）	多人犯罪（§27 II）
未了未遂	消極停止即可	**不適用**未了/既了區分
既了未遂	積極防果	一律須**積極防果**
核心要求	視情況而定	必須積極阻止結果發生

- 多人犯罪中，即使行為人自己停手，其他共犯仍可能繼續完成犯罪，因此**必須積極防止結果發生**才能成立終止未遂

二、§27 II 的射程範圍

- **適用對象**：共同正犯、教唆犯、幫助犯
- **不適用對象**：
    - 被教唆／幫助的**單獨正犯** → 回歸 §27 I
    - 間接正犯的**工具人** → 回歸 §27 I

三、法律性質

- 終止未遂 ＝ **個人減免刑罰事由**（位於三階之外）
- 僅對**實際有終止行為**的人發生效力，不及於其他共犯

參與犯的脫離（共犯脫離）

一、問題意識

- 某人原為共同正犯，中途想退出，但其他共犯繼續犯罪並既遂
- 若無脫離理論：退出者仍依「一人既遂，全體既遂」負既遂責任

二、脫離與終止未遂的體系定位（極重要，常被搞混！）

比較項目	脫離	終止未遂
體系位置	**構成要件**層次	三階之外（個人減免刑罰事由）
影響效果	影響既遂／未遂、有罪／無罪	僅影響刑罰減免
判斷時點	可在著手前或著手後	僅在著手後、既遂前

> ⚠ 很多考生搞混脫離與終止未遂的位置，這是常見錯誤！

三、實務見解：因果關係切斷說

- **不區分**著手前或著手後，採統一標準
- 必須切斷兩種因果：
    1. **心理上的因果**：告知同夥不幹了、勸阻
    2. **物理上的因果**：收回提供的工具、讓提供的資訊無用化
- 判斷原則：
    - 有提供貢獻 → 必須切斷該貢獻的因果
    - 無物理貢獻 → 無需物理切斷
- **切斷成功** → 從該時刻起不再是共同正犯
- **切斷失敗** → 仍為共同正犯，為最後結果負責

四、許玉秀老師見解

- 脫離失敗者雖仍為最後結果負責，但**可改論較輕的共犯形態**（教唆犯或幫助犯）

五、脫離成功後可適用終止未遂

- 脫離成功 → 法律上只負未遂責任 → 可進一步論終止未遂
- 即使被害人最終死亡，脫離成功者在法律上僅論未遂

六、經典考題分析（102年）

行為人	行為態樣	結論
甲	從頭到尾參與	殺人既遂
乙	著手後脫離成功（心理＋物理切斷）	單獨論殺人未遂 → 可適用終止未遂
丙	著手前因害怕而未到場，但未切斷因果	殺人既遂（共謀共同正犯）

七、寫作策略：分開寫 vs 一起寫

- **分開寫**：每人角色不同時，先寫行為最完整者
- **一起寫**：角色相同時
- 此為策略選擇，非對錯問題

八、特殊情形

（一）著手前脫離成功

- 不再是共同正犯
- 但仍可能論**預備犯**（預備行為無從否認）

（二）著手後脫離＋逾越（高考法制考題）

- 丙見乙拿槍（逾越犯意聯絡範圍）→ 悄悄離開但未切斷因果
- 逾越部分不負責 ＋ 脫離失敗：
    - **通說**：仍為傷害罪共同正犯
    - **許玉秀說**：可降為幫助犯

必要的參與犯（必要共犯）

一、問題核心

- 必要參與者之間（**內部關係**），有無 §28（共同正犯）、§29（教唆犯）、§30（幫助犯）的適用？
- **外部關係**不受影響（第三人對必要參與者仍可論共犯）
- **定義**：犯罪本質上需要多數**行為人**才能成立（被害人不算）

二、聚合犯

- 定義：多數行為人朝**相同目標**行動（如 §136 聚眾妨害公務罪）
- §136 區分三種角色：**首謀**、**下手施暴**、**在場助勢**

情形	可否論共同正犯
下手施暴者之間	☑ 可以
在場助勢者之間	☑ 可以
不同角色之間（如首謀 vs 在場助勢）	✗ 不可以（罪名不同）

- **結論**：參與情態相同的人之間可論共同正犯，不同則各論各的

三、對向犯

- 定義：雙方當事人立於**對立而合致**的地位
- 三種類型：

類型	例子	處理方式
雙方都罰且罰則相同	通姦罪（已廢除）	各論各的罪
雙方都罰但輕重不同	行賄（§122 III）vs 受賄（§122 I）	各論各的罪
只罰一方	販賣猥褻物品（§235，只罰賣方）	他方無罪，不可迂迴論共犯

- **核心原則**：對向犯的相對人之間，**不可論共同正犯、教唆犯、幫助犯**
    - 有罰雙方 → 各論各的罪
    - 只罰一方 → 他方不能再迂迴論正犯或共犯（立法者已決定不罰）
- **例**：行賄公務員，不可論為「教唆受賄」；買A片者不可論為「教唆販賣」

四、內部關係 vs 外部關係

- **內部關係**：必要參與者之間 → 受上述限制
- **外部關係**：第三人對必要參與者 → 不受限制，可正常論共犯
    - 例：我慫恿路伯言去賣A片 → 我可以成立 §235 教唆犯

過失犯

一、基本原則

1. **以處罰故意犯為原則，過失犯為例外**：有罰過失的犯罪，條文會特別寫
2. **無故意 ≠ 必然有過失**：例如穿山豬裝在草叢學豬叫被誤射，射擊者可能無過失
3. **故意與過失不是排斥概念，而是包含概念**：故意殺人同時也該當過失致死

二、過失的種類

種類	定義	例子
有認識過失	有想到可能發生，但過度自信認為沒事	看到輪胎胎紋不足仍上路
無認識過失	事實上沒想到，但應該要想到	從不檢查胎紋

- 兩者**無區別實益**，考試不用特別區分
- 過失犯的操作重點在體系審查，**§14 條文本身不重要**

三、過失犯的體系：兩套理論

（一）客觀歸責體系（老師推薦）

- **支持者**：林鈺雄、林東茂
- 構成要件只看兩個東西：
    1. **條件因果**
    2. **客觀歸責**
- 兩個都通過就有過失，**不用另外寫注意義務違反、預見可能性**
- 優點：簡單好寫不會錯，直接套用故意犯學過的客觀歸責理論

（二）傳統體系（學界通說人數較多）

- **支持者**：王皇玉、許澤天、林書楷
- 構成要件檢討：
    1. 條件因果
    2. 行為不法：有無違反注意義務
    3. 結果不法：風險有無實現、結果可否避免

四、過失犯判斷重點永遠在客觀！

> ⚠ **極重要**：過失犯的判斷重點永遠在**客觀**，而不在主觀！

- 常見錯誤：把注意義務違反、預見可能性塞到主觀 → **學理上沒有這種體系**
- 通說：過失犯的構成要件根本**不用寫主觀**
- 不需要在主觀寫「行為人非出於故意」（故意與過失是包含關係）

五、構成要件 vs 罪責的區分

層次	判斷標準	內容
構成要件（客觀）	**一般人**的注意	理性謹慎第三人應有的注意（非國民平均）
罪責	**行為人個人**的能力	個人有無履行注意義務的能力

- **一般化理論**（通說）：構成要件看一般人注意，罪責看個人能力
- **個別化理論**（少數說，許玉秀早期引介）：個人能力拉到主觀構成要件判斷
    - 國內目前無學者特別採此說

過失犯的構成要件

一、條件因果

- 與故意犯相同，無特殊問題
- **注意**：過失犯的「行為」是自然事實，非法律評價
    - ☑ 行為 ＝ 開車
    - ❌ 行為 ≠ 超速（超速是法律對行為的評價）
    - 選錯行為 → 後面判斷全部跟著錯

二、客觀歸責

（一）製造法所不容許的風險

1. 信賴原則

- **基本概念**：遵守交通規則的人，可合理信賴他人也會遵守交通規則
- **功能**：限縮注意義務
- **適用範圍**：

領域	案例
交通	綠燈直行不需減速查看闖紅燈者
醫療	牙醫可信賴牙助會好好消毒器械
一般	依法設置電纜者可信賴不會有人舉導電物通過

- **不能主張信賴原則的情形**：

限制事由	說明
(一) 行為人違規在先	違反**保護他人安全**的規範（非純行政管制規範）
(二) 已預見被害者違規	信賴基礎消失

- 違規在先的精確定義：
    - ❌ 未帶行照駕照（行政管制）、未繫安全帶（保護自己）、偽造車牌 → 仍可主張
    - ☑ 超速、酒駕、學校附近未減速 → 不可主張
- **爭議**：行為人違規但就算不違規結果也會發生
    - **多數說**：違規者不能主張信賴原則（但到風險實現層次以「結果不可避免」處理）
    - **少數說**：既然不違規結果也會發生，應例外讓其主張

2. 違反法規範或工作規範

- 有法律規定時：以法律為參考
- 無法律規定時：**利益衡量**
    - 例：在有幼兒家庭中，將老鼠藥放在茶几上 → 利益（一時方便）＜ 危險（幼兒誤食）→ 有製造法所不容許的風險

3. 無照駕駛 ≠ 製造法所不容許的風險

- 台灣考照制度下，有無駕照與有無駕駛能力**無直接關係**
- 被吊扣／吊銷駕照的人事實上仍有駕駛能力
- 判斷風險的重點在**超速、疲勞駕駛**等實質違規

（二）風險實現

1. 結果的可避免性（義務違反的關聯性）

- 又稱：結果的不可避免性
- **內涵**：行為人就算遵守規範，結果也還是會發生 → 結果不可歸責
- **經典案例**：

    - **山羊毛案**：女工感染的細菌即使消毒也殺不死
    - **超速撞死違規左轉者**：即使開50km/h也來不及反應、撞上也會死

- **不能用「遲延抵達」論證因果關係**：

    - 速限目的是讓駕駛人**來得及反應、煞得住**
    - 不是讓肇事者「晚到現場就不會撞到」

2. 風險升高理論

- **適用前提**：**無法確定**行為人履行義務後結果是否仍會發生

學說	處理方式
多數說	罪疑惟輕 → 結果不可歸責
風險升高理論	行為人違規已升高風險 → 結果仍可歸責

- 風險升高理論的辯護：

    - 罪疑惟輕適用於**已發生的事實**不明
    - 本案屬於**假設事實**不明（假設行為人不違規，結果會如何）
    - 假設事實 ≠ 已發生事實 → 不適用罪疑惟輕

> ⚠ 常見錯誤：濫用風險升高理論。此理論**僅適用於無法確定**結果是否可避免的情形，若已確定不可避免，直接用「結果不可避免」即可。

3. 被害人自我負責

- 與故意犯相同，無特殊問題
- 例：資源回收車司機站在後車廂踏板摔死 → 應論被害人自我負責（非常態性問題）

    - 實務曾錯用「欠缺相當因果關係」，學理上應以被害人自我負責否定

過失犯的違法性

一、要不要看主觀？

肯定說（多數說）

- 過失犯的阻卻違法也需要主觀要件

學者	主觀要求程度	結論
林鈺雄	保全法益的目的	過失犯不可能阻卻違法（過失 = 不小心，不可能有保全法益意思）
陳志平	對應現在不法侵害的意思	過失犯**可以**阻卻違法

- 陳志平說的案例：甲被乙追殺，邊跑邊拿槍警告，不小心扣到板機打死乙 → 甲知道現在不法侵害 → 可阻卻違法

否定說（林書楷）

- 過失犯的違法性**不用看主觀**，客觀符合即阻卻
- 理由：

    - 構成要件該當 ＋ 違法性 ＝ 不法
    - 正面不法（構成要件）不用看主觀 → 負面不法（違法性）也不用看

- **重要推論**：採否定說 → 過失犯**永遠不會有偶然防衛／偶然避難**

二、過失犯的誤想防衛（許恆達老師文章）

- **問題**：故意犯誤想防衛 = 阻卻故意改論過失，但過失犯本來就過失了，要怎麼處理？

學說	處理方式	許恆達態度
嚴格罪責論	§16 不法意識欠缺	❌ 誤想防衛是誤認事實非誤認法律；過失犯減刑無實益
限制罪責論	類推適用構成要件錯誤（德國§16 I）	❌ 台灣無對應法條；跳脫階層論
期待可能性理論	欠缺期待可能性	❌ 太籠統模糊
限制法律效果的罪責理論	阻卻罪責故意 → 過失犯則連過失都阻卻	☑ 通說

- **限制法律效果的罪責理論在過失犯的適用**：

- 行為人須對「構成要件實現」+「無阻卻違法事由」兩者都有預見可能性
- 任一無預見可能性 → 連過失都阻卻 → 無罪

過失犯的罪責

一、主觀的避免可能性

- 行為人個人有無履行注意義務的能力
- 個人能力特別差 → 阻卻罪責，不成立犯罪
- **例**：新手駕駛第一天上國道遇爆胎，慌張讓車翻覆 → 構成要件有過失（一般人不該如此），但罪責層次阻卻（個人無此能力）

二、超越承擔的過失（近年重要考點）

- **概念**：行為人知道自己欠缺能力，仍硬要做，且從一般人觀點來看不應該做
- **與新手駕駛的區別**：新手不讓上路就永遠學不會；超越承擔是明知不會還硬幹

處理方式（與原因自由行為思維一致）

學說	思維	對應
犯行前置說	開遊覽車當下不能論罪（無能力）→ 用「決定開遊覽車上路」的前行為論罪	≈ 原因自由行為**構成要件模式**
個人能力欠缺的不予考量	行為人濫用個人能力欠缺抗辯 → 不予考量	≈ 原因自由行為**例外模式**（許恆達採）

過失犯論罪的重要技巧：前行為論罪

- 過失犯幾乎都是**非定型犯罪**
- 造成結果的當下行為若無法論罪（如無意識、欠缺刑法行為），**退而求其次論前行為**

案例	當下行為（不能論罪）	前行為（用來論罪）
疲勞駕駛撞死人	睡著撞人（無刑法行為）	以疲勞狀態上路 → 過失致死
酒後壓死嬰兒	翻身壓死兒子（無意識）	酒醉後睡在兒子旁邊 → 過失致死
被鳥啄衝上人行道	衝上人行道撞人（罪責阻卻：無個人能力）	開窗駕車（無製造法所不容許風險→無罪）
遊覽車翻覆	開車當下（無能力）	決定開遊覽車上路 → 過失致死

考題解析

一、超速無照撞死違規左轉者

- **行為**＝開車（非超速，超速是法律評價）
- 條件因果：☑ 有
- 製造法所不容許的風險：**以超速認定**（非無照）
- 信賴原則：多數說 → 違規在先不可主張
- 風險實現：結果**不可避免**（即使遵守速限也來不及反應、撞上也會死）→ 不成立犯罪

二、甲叫乙送貨，乙無照疲勞駕駛撞死人

- **乙**：以疲勞駕駛上路論過失致死罪（非以無照論）
- **甲**：無過失——可合理信賴有駕駛能力的兒子不會亂搞（信賴原則）

三、鳥擊案

- **駕車衝上人行道**：構成要件有過失（一般人不該如此），但罪責阻卻（驚慌失措，欠缺個人能力）→ 不成立
- **開窗駕車**：無製造法所不容許的風險（開窗駕車是常見行為），退一步就算有風險也無實現（被鳥攻擊太罕見，無常態性）→ 不成立
- 寫作順序：先論前行為（開窗），再論後行為（衝上人行道）

四、資源回收車踏板摔死案

- 實務以「欠缺相當因果關係」否定 → **學理上不妥**
- 正確應以**被害人自我負責**否定過失犯成立（無人逼其站在踏板上）

五、苦藤粉案

- 苦藤粉非中藥、非西藥，就是一般可食用的植物粉
- 無製造法所不容許的風險（如同給朋友吃堅果，結果對方堅果過敏死亡）
- 傳統體系：行為人無違反客觀注意義務

- **結論**：無罪